

0003848-72.2010.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003848-72.2010.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003848-72.2010.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 138/2010 - 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tulio Marcio Santos Amorim

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

TÚLIO MÁRCIO SANTOS AMORIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 171, "caput", do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01-D/02-D), no dia 07 de janeiro de 2010, por volta das 14h31, na Praça Barão do Rio Branco, nº 90, Centro, neste Município e Comarca, obteve para si vantagem patrimonial ilícita de R\$ 310,26 (trezentos e dez reais e vinte e seis centavos), em prejuízo de FERNANDO YAJIMA, após induzi-lo em erro por meio fraudulento. Segundo o apurado, o acusado, proprietário da empresa COMPRANET, mantinha na internet o site www.compranet.com.br para venda de mercadorias eletrônicas, já alimentando o desiderato de não honrar o convencionado e causar o inadimplemento por pré-constituído propósito. Consta da denúncia que a vítima, ao realizar pesquisa na internet, efetuou no site supramencionado a compra de uma câmera digital, no importe de R\$310,26 (trezentos e dez reais e vinte e seis centavos), pagando o produto por intermédio de depósito na conta do acusado, sendo avençado que a entrega se daria em 20 de janeiro de 2010. Extrai-se, também, da denúncia que a câmera digital não foi entregue na data combinada e a vítima não conseguiu mais contato com o réu, tampouco obteve a devolução do dinheiro consoante solicitado. Verte, por fim, que o acusado, animado do antecipado e deliberado escopo de frustração do lesado em sua perspectiva econômica, deixou, arditamente, de cumprir o negócio jurídico pactuado, utilizando-se do site como meio iludente,

artifício, embuste ou engodo para captar e ilaquear a boa-fé alheia, obtendo, com esse enlço, a vantagem ilícita almejada.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: portaria (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 3/4) e ofício de solicitação do cancelamento da compra, realizado pelo PROCON e instruído com o boleto bancário quitado pela vítima e notícia veiculada acerca da ocorrência de fraude vinculada à empresa do acusado (fls. 6/9).

Houve a prolação de sentença, julgado extinta a punibilidade doo acusado, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição (fls. 95/96), ao que o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 99/103), contrarrazoado a fls. 109/110 pela defensora dativa nomeada ao acusado (fl. 107), tendo o Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo dado provimento ao recurso em 27 de agosto de 2015, para anular a sentença, recebendo a denúncia e determinando o prosseguimento do feito (fls. 124/128), com certificação do trânsito em julgado a fls. 130 e 135.

Por decisão de fls. 137/vº, foi determinada a citação do acusado.

Após infrutíferas tentativas de localização (fls. 147, 163, 190 e 192), o acusado foi citado por edital (fls. 195/196) e, por intermédio do defensor constituído (fl. 204), se manifestou a fls. 201/203, aduzindo ter sido condenado em razão do cometimento do delito de estelionato, em continuidade delitiva, conforme sentença prolatada nos autos da ação penal de nº 0024-10.059.960-4, tramitada perante a Comarca de Belo Horizonte (MG), em razão do que requereu o acolhimento da exceção de coisa julgada, com fundamento no art. 110, do Código de Processo Penal. Juntou procuração e documentos (fls. 204/321).

Por decisão de fl. 327, foi determinada a expedição de ofício à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte (MG), solicitando-se informações acerca de eventual presença da vítima FERNANDO YAJIMA na ação penal tramitada sob nº 024.10.059.960-4, junto à referida Comarca, ao que sobreveio a mensagem eletrônica e o anexo de fls. 331/332.

O Parquet manifestou-se à fl. 334, opinando não haver litispendência ou coisa julgada.

Em decisão de fl. 336, foi indeferido o pleito de reconhecimento de ocorrência de coisa julgada.

O réu, por seu procurador constituído (fl. 204), ofertou resposta à acusação (fls. 339/345), batendo-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, em razão da ausência de narrativa de elementos essenciais do delito imputado, tendo reiterado o pleito de reconhecimento da ocorrência de coisa julgada.

Subsidiariamente, na hipótese de inacolhimento das prejudiciais, requereu o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo afastamento das preliminares arguidas, reiterando sua manifestação de fl. 337 (fl. 349).

Por decisão de fl. 351, determinou-se a intimação da vítima para comparecimento na Unidade Judicial com vistas à formalização da representação, o que foi reconsiderado em decisão exarada à fl. 365.

Em decisão de fl. 366, foi afastada a preliminar concernente à inépcia de denúncia, consignando-se, ainda, que não foram vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, sendo designada a realização de audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução, foram tomadas as declarações da vítima e interrogado o acusado (fls. 404/vº).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação do réu, nos termos da denúncia, vez que comprovadas autoria e materialidade delitivas, salientando que eventuais dificuldades financeiras não justificariam a não entrega da mercadoria comercializada (fls. 404/vº).

Já a Defesa, em seus memoriais escritos (fls. 406/410), reiterou o pleito de reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, sob o fundamento de que foi condenado pelo mesmo crime, na modalidade continuada, no período compreendido em 09/02/2005 a 13/03/2010, em favor de "incontáveis vítimas, de várias regiões do país", a abarcar a vítima Fernando Yajima, pese a ausência de sua individualização no rol dos ofendidos. Obtemperou ter passado por dificuldades financeiras, em razão da não entrega dos produtos por seus fornecedores, o que impossibilitou o

adimplemento dos compromissos com seus clientes, a caracterizar a atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo. Aduziu que se dispôs a reparar o dano carreado à vítima, por meio de restituição do valor por esta despendido, consoante depósito judicial juntado. Requereu sua absolvição, tendo, subsidiariamente, na eventualidade de condenação, pugnado pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, em complemento ao decidido a fls. 366 e 336, consigno que os pleitos de rejeição da denúncia sob a alegação de ausência de justa causa e de reconhecimento da ocorrência de coisa julgada (fls. 339/345 e 406/410) devem ser afastados.

É dever funcional do órgão do Ministério Público, diante de indícios configuradores de ação criminosa, apresentar denúncia para que, no momento oportuno, qual seja a ação penal, e sob o crivo do contraditório, sejam minuciosamente apurados os fatos e seus autores.

A denúncia, portanto, deve preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias e o suposto autor, bem como classificando penalmente a conduta, o que foi realizado de forma adequada pela peça inicial de fls. 01-D/02-D.

Em suma, a denúncia atendeu a todos os requisitos legais, possibilitando ao acusado que se defendesse dos fatos que lhe foram imputados e exercitasse plenamente seu direito constitucional de defesa.

Tampouco vinga a sustentada ocorrência de coisa julgada sob o argumento de que já sofreu condenação em razão da ofensa perpetrada em desfavor de “incontáveis vítimas, de várias regiões do país”, na medida em que, cuidando-se de crime por fatos semelhantes praticado contra vítima individualizada, não há se falar na hipótese de litispendência ou coisa julgada.

Em análogo sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Estelionato. Réu que se fazia passar por fiscal da Caixa Econômica Federal e obtinha mediante este engodo dinheiro para falso cadastramento para casa própria. Obtenção de vantagem mediante ardil em prejuízo do patrimônio da vítima.

Configuração do delito. Extinção da punibilidade das condenações anteriores há menos de cinco anos. Validade para aumento da pena base. Não compensada a confissão com as reincidências múltiplas e específicas. Mantida a fração de aumento pela continuidade. Desprovimento. (...) Quanto à autoria, o réu confessou em juízo ter praticado o crime, confirmando os fatos denunciados e anotou que já foi condenado pela prática desse crime, cumprindo pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado. Trata-se de crimes por fatos semelhantes praticados em datas distintas e outras vítimas, que não se confundem com o descrito na denúncia, não sendo hipótese de litispendência ou coisa julgada. (...) Nas investigações verificou que várias vítimas foram enganadas pagando R\$ 100,00 cada uma e que não foram ressarcidas. (...) (TJ-SP - APR: 00186627920138260576 SP 0018662-79.2013.8.26.0576, Relator: Costabile e Solimene, Data de Julgamento: 14/03/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2019, ênfase apostas).

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada procedente.

Para além da prova oral, a materialidade restou demonstrada por meio dos seguintes documentos: portaria (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 3/4) e ofício de solicitação do cancelamento da compra, realizado pelo PROCON e instruído com o boleto bancário quitado pela vítima e notícia veiculada acerca da ocorrência de fraude vinculada à empresa do acusado (fls. 6/9).

A autoria é igualmente certa e convergiu para o acusado.

Nesse sentido, a vítima FERNANDO YAJIMA, em solo policial (fl. 5), declarou in verbis que: em 7 de janeiro efetuou pela internet compra de uma câmera digital pela empresa COMPRANET, efetuando o depósito de R\$310,26 em conta de TÚLIO MÁRCIO SANTOS AMORIM; a mercadoria não foi entregue até a presente data, sendo que site fechou; teve conhecimento que TÚLIO MÁRCIO SANTOS AMORIM teria sido inclusive preso por estelionato (Sic).

Ouvido em juízo, o ofendido FERNANDO YAJIMA declarou ter comprado uma câmera fotográfica pela internet, a qual nunca recebeu, vindo, posteriormente, após realizar pesquisas na rede, a descobrir ter sido vítima de ação de estelionato; asseverou que a compra foi realizada diretamente no sítio do acusado, não se cuidando de aquisição sob a modalidade e-commerce ou marketplace. Em atendimento às reperguntas da acusação, afirmou ter realizado a aquisição de câmera fotográfica no sítio www.compranet.com.br, efetuando o pagamento por meio de boleto bancário; asseverou ter buscado contato com o réu, mas não houve resposta, não tendo sido entregue sua mercadoria, tampouco lhe sido devolvido o valor pago; consignou ter realizado pesquisas na internet, vindo a constatar que havia vários casos semelhantes de fraudes sofridas por consumidores, bem como que o réu havia sido detido pela prática de estelionato; disse, por fim, que somente registrou boletim de ocorrência (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico referido à fl. 404vº, ênfase aposte).

Por sua vez, o acusado TÚLIO MARCIO SANTOS AMORIM, interrogado em sede de inquérito policial (fl. 141), contou in verbis que: (...) era proprietário da empresa denominada COMPRANET, sendo que efetuava vendas pela Internet; que em novembro do ano de 2009, o declarante teve problemas financeiros, pois comprou algumas mercadorias e não as recebeu, não tendo como ressarcir seus clientes, que adquiriram os produtos no site; Que referente FERNANDO YAJIMA afirma que "não teve como verificar se realmente ele efetuou a compra e o pagamento da câmera digital", pois em março de 2010 o declarante teve toda a documentação e computadores apreendidos, referente a empresa COMPRANET, pela polícia militar a pedido do Ministério Público: Que o declarante alega que respondeu processo, inclusive foi condenado e ficou preso em Belo Horizonte, por crime de estelionato, referente à empresa COMPRANET: Que o declarante afirma que se dispõe a ressarcir a vítima FERNANDO YAJIMA, pelo prejuízo, caso o mesmo tenha como provar o depósito efetuado referente a compra da câmera digital (Sic).

Interrogado em juízo, TÚLIO MARCIO SANTOS AMORIM afirmou que, em 2007, abriu uma empresa de vendas pela internet, sobrevivendo-lhe dificuldades financeiras no final do ano de 2009, ao que não conseguiu honrar os compromissos assumidos com os clientes. Confessou ter realizado a venda para a vítima FERNANDO YAJIMA e não ter lhe entregado o produto, bem como que tentou ressarcir-la, mas não teve outros contatos com o ofendido. Em atendimento às reperguntas da Acusação, confirmou que era proprietário da empresa www.compranet.com.br e que realizou a venda para a referida vítima; respondeu a ação criminal, no Estado de Minas Gerais, pelos mesmos fatos, ocorridos em 2010, envolvendo várias vítimas, tendo sido condenado e cumprido pena até 2012 ou 2013; afiançou que tentou ressarcir as vítimas (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico referido à fl. 404º, ênfase aposte).

Pois bem.

O artigo 171, "caput", do Código Penal, tipifica a conduta do agente que obtém para si, ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Portanto, há necessidade de dolo no comportamento do agente, consistente no voluntário emprego de engano preordenado para fraudar a eleita vítima. E, na espécie, ficou patente que o réu agiu com referido dolo específico.

Como bem descrito na denúncia, relatado especialmente pela vítima em solo policial e confirmado em juízo, o réu obteve vantagem ilícita em prejuízo do ofendido, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício e ardil, com o fim de obter vantagem patrimonial ilícita.

Houve premeditação de realização de anúncio de venda de uma câmera digital que se sabia que não iria entregar, nos termos da promessa comercial, e, com isso, se cooptou a vítima, cujas palavras expostas ao longo da instrução criminal exprimem a confiança criada nela de que estivesse diante de fidedigno vendedor de produtos eletroeletrônicos, reforçada a narrativa pelo pagamento do boleto bancário relativo à aquisição efetuada junto ao sítio www.compranet.com.br (fls. 6/7).

Importante destacar que a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade da vítima neste processo, nem mesmo que tivesse ela qualquer razão escusa para

pretender prejudicar o réu. Assim, suas declarações não de ser prestigiadas, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e são coerentes, formando um todo harmônico e lógico.

A seu turno, a alegação do acusado de que lhe sobrevieram dificuldades financeiras, as quais impediram a entrega das mercadorias comercializadas, não lhe serve de lenitivo, na medida em que, se, de fato, teve problemas com fornecedores que não lhe entregaram os produtos para serem comercializados, deveria ter encerrado ou, ainda, suspenso as atividades de venda em seu sítio www.compranet.com.br, a fim de que a vítima, bem como outras pessoas incautas, não realizassem a compra de produtos eletroeletrônicos, o que não se verificou na espécie.

Por oportuno, trago à colação ementa de similar ação concernente à venda de produtos, pela internet, a inúmeras vítimas, sem a realização da devida entrega aos consumidores, em intrincado e vultoso esquema delitivo, no qual figurou o réu, ao que se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - (...) - ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL E COM OS DEMAIS INDÍCIOS - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - PERSONALIDADE - NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA SUA AFERIÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de crimes praticados em sequência, através da internet, em diversas comarcas, o foro de qualquer delas é competente para o processamento e julgamento do feito, ficando preventa a competência do magistrado que primeiro praticar qualquer ato decisório, consoante o disposto no art. 83 do CPP; - Eventuais vícios ou irregularidades ocorridos na fase de inquérito policial não acarretam a nulidade do processo, não havendo que se falar em "ilicitude" passível de macular as provas derivadas, ou mesmo o feito; (...); - A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos elementos materiais coligidos e dos demais indícios, é o suficiente para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado; - O exame da personalidade do agente não pode ser feito a contento pelo magistrado, no âmbito restrito da ciência penal, sendo necessária prova técnica sobre o assunto, elaborada por profissionais capacitados à análise das características psíquicas do homem. (...) Na fase judicial o ofendido ainda acrescentou: "...teve prejuízo efetivo, uma vez que não recebeu o produto que pretendia adquirir e nem o seu dinheiro de volta, até a presente data; (...) Vê-se, portanto, que a partir deste único depoimento já é possível verificar uma autêntica prática do crime de estelionato, porquanto os recorrentes procederam à alienação de mercadorias que de antemão sabiam que não iriam entregar, mantendo a vítima, um inocente cliente, em erro, através de meio fraudulento, para, assim, aferirem vantagem econômica em prejuízo alheio. As provas dos autos, porém, ainda vão além, demonstrando que Rodrigo foi apenas uma das infindáveis vítimas deste grupo criminoso formado pelos recorrentes, o qual, ressalte-se, era estável, permanente e voltado para a prática continuada de delitos de estelionato por meio da internet. Não obstante terem os réus negado a autoria dos fatos, suas negativas encontram-se totalmente divorciadas do conjunto probatório, sendo que os fatos elementos de convicção coligidos ao feito apontam, sem a menor sombra de dúvidas, o envolvimento de Túlio, Simone, Iolanda, Cléber, Bruno e Gisele nos delitos sub examine. Em verdade, as bem sucedidas investigações comprovaram que os réus obtiveram vantagem patrimonial indevida em detrimento de vítimas do país inteiro, alcançando seus golpes cifras de centenas de milhares de reais (consoante movimentação financeira obtida na residência do corréu Túlio), dinheiro este cuja natureza os réus tentaram dissimular e/ou ocultar pelos mais diversos meios, inclusive com a construção de um luxuoso restaurante, como veremos adiante. Conforme apurado, o apelante Túlio, que era o chefe da quadrilha, juntamente com os demais corréus, cada um no desempenho de uma função específica e de igual importância no grupo - como veremos adiante -, mantinham diversos sites de vendas na internet, através dos quais simulavam vendas de produtos dos mais variados, recebendo o valor pelo pagamento sem contudo efetuar as entregas. Restou apurado, também, que, como é comum em crimes desta espécie, os réus elegiam alguns clientes específicos para receberem os produtos, de modo a

levantar a menor suspeita possível contra os sites, aumentando, assim, o número de vítimas e, conseqüentemente, os proveitos do delito, o que facilmente se percebe pelas relações de vítimas/débitos de fls. 307/325 e 329/337. Para uma melhor elucidação dos fatos, passo a uma breve exposição da conduta individualizada dos apelantes, segundo as provas dos autos: Os réus Túlio e Simone eram os mentores e líderes da quadrilha, sendo o primeiro responsável direto pela direção dos negócios escusos do grupo, inclusive as movimentações financeiras, consoante suas próprias declarações. Além dos sites www.netinformatica.org e www.compranet.com.br, os quais, ressalte-se, estavam no ar desde de 2005, Túlio ainda registrou outros três domínios, quais sejam, www.clikshop.com.br, www.tokperfumes.com.br e www.komerci.com.br, todos com uma mesma finalidade, auferir lucro de maneira fácil e ilícita. Durante as investigações, Túlio foi surpreendido na posse de diversos documentos que o ligam de forma inconcussa aos delitos em questão, dentre os quais vários talões de cheques da empresa Shop Certo, a qual era por ele utilizada para movimentar o dinheiro recebido das vítimas dos demais sites que estavam sob o seu controle, fato este que é comprovado, inclusive, pelos emails que foram encontrados no notebook periciado. Insta salientar que tamanho é o instinto embusteiro do recorrente que, como bem salientou o i. juiz sentenciante, tentou ele ludibriar até mesmo o magistrado, mas acabou caindo em constantes contradições, as quais reforçam ainda mais sua participação nos crimes. (...) (TJ-MG - APR: 0599604-16.2010.8.26.0024; APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.059960-4/001- COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1º APELANTE: SIMONE APARECIDA CAMPOS DE AMORIM, TULIO MARCIO SANTOS AMORIM Belo Horizonte, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 28/08/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/09/2012, ênfase aposta).

Demais disso, a própria confissão do réu em juízo é válida, porquanto em consonância com as demais provas produzidas no processo.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal: As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

No mais, havendo elementos indicativos da realização do ressarcimento do prejuízo à vítima, consoante se verifica do depósito judicial comprovado pelo acusado a fls. 411/413, não haveria se falar no arrependimento posterior previsto no artigo 16, do Código Penal, porque requer, para sua caracterização, o ato voluntário do agente, e seu integral ressarcimento até o recebimento da denúncia. Todavia, pode o ressarcimento do dano, no presente caso, constituir circunstância atenuante da pena conforme dispõe o art. 65, III, alínea "b", do Código Penal, eis que realizado antes do julgamento.

De resto, pese o quanto sustentado pela combativa Defesa, o fato é típico, inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, de modo que é imperioso o reconhecimento da prática pelo réu do delito de estelionato, afastando-se a alegação de ausência de dolo e todas as demais teses defensivas.

Delineada a responsabilidade do réu pelo evento e integralmente procedente a denúncia, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, as condições judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, são desfavoráveis ao acusado, eis que, à vista das cópias de autos, folha de antecedentes e certidões acostadas a fls. 209/321, 369, 372, 384/388 e 393/400 é possível identificar, ao menos, uma condenação definitiva anterior com força para caracterizar maus antecedentes específicos (processo nº 0599604-16.2010.8.13.0024 - art. 171, caput, c.c. art. 288, caput, c.c. arts. 71 e 29, todos do CP, e art. 1º, da Lei nº 9.613/98). Dessa forma, a pena-base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, a resultar 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Faz-se necessário esclarecer que ações penais em andamento não podem ser levadas em consideração para aumento da pena-base (Súmula 444, STJ).

De igual diapasão, pontue-se ser inviável a exasperação da pena por condenações do

réu por fatos posteriores. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO, HOMICÍDIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA. [...] 2. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. [...] (HC 243.829/DF Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017).

Nada obstante, perfeitamente viável a consideração dos maus antecedentes quando o fato é anterior e o trânsito em julgado posterior ao crime em testilha. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal em destaque, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. Habeas corpus não conhecido (HC 319.498/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11/06/2015 ênfase apostas).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e estão presentes as atenuantes da confissão espontânea em juízo, bem como da realização de reparação de dano à vítima, por meio de depósito judicial (fls. 412/413), razão pela qual a pena deve retornar ao mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, vedada a redução nesta fase para aquém do mínimo legal, consoante Súmula nº 231, do C. STJ. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no patamar anteriormente fixado.

Cada dia-multa fica estabelecido no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos sobre a exata situação econômica do réu.

Por fim, sendo o réu tecnicamente primário, sopesando-se os maus antecedentes com a confissão, bem como em razão de o acusado, por sua espontânea vontade, buscar minorar as consequências do delito, por meio de por meio de reparação do dano à vítima (fls. 412/13) e levando-se em consideração ainda que a pena aplicada não é superior a quatro anos e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, cabível a concessão, em seu favor, dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes, do Código Penal.

Haja vista que a pena aplicada não é superior a um ano, possível a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser revertido em prol de entidade com destinação social cadastrada junto ao Juízo, conforme restar definido pelo Juízo da Execução, sem prejuízo da pena de multa.

A medida, além de socialmente recomendável, é suficiente para repressão e prevenção da conduta.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu TÚLIO MÁRCIO SANTOS AMORIM, qualificado nos autos, como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito nos termos da fundamentação, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Destaque-se que, em não havendo recurso por parte do Ministério Público, considerando as penas ora aplicadas, bem assim a somatória do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia em 27/08/2015 (fls. 124/128) e a presente data (25/11/2022), superior a quatro anos, desde logo, fica declarada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, com base na pena concreta, com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, V, artigo 110, "caput" e § 1º, artigo 114, II, e artigo 117, I e IV, todos do Código Penal, devendo a Unidade Judicial promover as comunicações e anotações de praxe.

Nada obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, condição em que a pena é considerada extinta, é certo que subsistem os demais efeitos da condenação e, dentre eles, encontra-se a responsabilização civil.

Nesse sentido, prelecionam Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim: A sentença penal condenatória é dotada de efeito anexo e extrapenal de tornar certa a reparação do dano, e, a respeito da separação das justiças civil e repressiva, assumiu a condição de título executivo civil, desde o advento do art. 63 do CPP, passando pelo revogado art. 584, inc. II, e chegando ao art. 475-N, inc. II. Este efeito anexo decorre da circunstância de o mesmo fato ilícito incidir, simultaneamente, em duas regras, a penal e a civil, gerando duas ações a ação penal toca, como regra, ao Ministério Público; a ação reparatória cabe à vítima e, consequentemente, o delicado e grave problema de coordená-las quanto aos resultados. No direito pátrio, vigora o sistema da independência (o ilícito civil não pode ser resolvido no âmbito penal) com o temperamento do art. 69 do CPP, ou seja, a vítima que não ingressou com a ação reparatória não precisará mais fazê-lo, uma vez condenado o autor do ato ilícito, pois a sentença penal adquire eficácia de título executivo, e algumas influências recíprocas. É vedada a discussão das questões já decididas no juízo penal pelo juízo cível, como a culpa, o dolo etc. Resta, assim, ao juízo cível, delimitar questões relativas ao quantum indenizatório ou a execução forçada. Observe-se, a esse respeito, o que prescreve o parágrafo único do art. 63 do Código de Processo Penal, com redação da Lei

nº 11.719/08: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". O art. 387, inc. IV do CPP, de outro lado, estabelece que o juiz criminal, ao sentenciar, deverá fixar valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Em linhas gerais, dá-se a vítima do ilícito civil a opção de aguardar o desfecho do processo-crime ou de ingressar, imediatamente, com a ação civil de reparação de dano. Evidentemente, só a sentença definitiva, e transitada em julgado, adquire eficácia executiva para o art. 475-N, inc. II. O efeito extrapenal é automático e não carece de explicitações no provimento. Observe-se que a sentença penal produz efeitos cíveis ainda que, posteriormente, se reconheça a prescrição da pretensão punitiva, retroativamente, com base na pena fixada em concreto, conforme decisões do STJ (Comentários ao Código de Processo Civil 1ª Ed. GZ 2012, p.726/727 -ênfase apostas).

A respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO CIVIL DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, AINDA QUE POSTERIORMENTE SE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA EM CONCRETO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA RELACIONADA À ALEGADA POBREZA DA PARTE. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO BENEFÍCIO, SE DEMONSTRADA SUA DESNECESSIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DAS PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. A sentença penal condenatória produz efeitos cíveis, ainda que, posteriormente, se reconheça a prescrição da pretensão punitiva, retroativamente, com base na pena fixada em concreto.- Ao art. 67, II, CPP, deve-se

dar interpretação que prestigie o princípio constitucional da razoável duração do processo. Havendo certeza sobre o ilícito, "a decisão que julgar extinga a punibilidade" não impedirá, em sentido amplo, a propositura de "ação civil", ou seja, ação de conhecimento, execução ou cautelar. Entendimento diverso importaria ao jurisdicionado o ônus de suportar a duração de dois processos de conhecimento, um na esfera cível e outro na criminal, para que se julguem rigorosamente os mesmos fatos (REsp nº 789.251 - RS STJ 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi j. 11.11.2008 ênfase apostas).

No mesmo diapasão, pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Liquidação de sentença penal condenatória. Extinção, sem análise de mérito, por ausência de título executivo, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em grau recursal. Entendimento da disposição contida no artigo 475-N, inciso II, do Código de Processo Civil ["São títulos executivos judiciais a sentença penal condenatória transitada em julgado"]. Configuradas a materialidade e autoria, ocorre a sentença condenatória, acarretando o surgimento do "jus puniendi" estatal. Esta consiste na possibilidade jurídica do Estado impor a sanção penal ao condenado. Referida autorização deve ser exercitada dentro de certo prazo, sob pena de perda de sua força executória. No caso presente, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva [antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória] e, nessas condições, a pena é considerada extinta, mas, subsistem os demais efeitos da condenação e, dentre eles, encontra-se a responsabilização civil. Decisão anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 02056132820118260100 SP 0205613-28.2011.8.26.0100, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 11/07/2012, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2012, ênfase apostas). Nesse passo, pese o reconhecimento da pretensão punitiva estatal, à vista das especificidades do caso concreto, considerando a liberalidade do acusado na realização de depósito judicial de fls. 411/412, feita a título indenizatório à vítima, autorizo, com o trânsito em julgado, seu levantamento em favor dela, sem prejuízo de eventual acionamento do juízo cível, submetendo-se as demais questões ao crivo do devido contraditório e da ampla produção probatória. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro ao réu o direito de recurso em liberdade.

Custas "ex lege".

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada à fl. 107 no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Providencie-se o que mais for necessário.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA